

1523738-69.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial, examinar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, 1º Pav., Rua 10, sala 329, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7171, São Paulo-SP - E-mail: sp29cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:1523738-69.2022.8.26.0228 - 2022/001268Classe - AssuntoAção Penal - Procedimento OrdinárioRéu:PAULO DE FREITAS GOMES

Aos 14 de dezembro de 2022, às 15:30 HORAS, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, na sala de audiências virtuais da 29ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Tatiana Franklin Regueira, comigo Assistente, foi declarada aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento designada nestes autos. Apregoados, compareceram o (a) Digníssimo (a) Promotor (a) de Justiça, Dr. (a) Maria do Carmo Galvão de Barros Toscano, o réu PAULO DE FREITAS GOMES e seu(sua) Defensor(a) Dr. Leandro de Castro Silva Defensoria Pública do Estado de São Paulo OAB 999999D/PE. Declarações e depoimento(s) colhido(s) pelo sistema audiovisual, gravados na plataforma Teams, com a concordância dos presentes. A qualificação dos presentes foi, nesta data, atualizada no sistema eletrônico e se encontra à disposição das partes, com as ressalvas do Provimento CG 32/2000, em se tratando de vítima ou testemunha protegida. Verificado, após indagação à vítima, que a presença do réu poderá lhe causar humilhação, temor ou sério constrangimento, de modo a prejudicar a veracidade do depoimento a ser prestado, foi determinada a retirada do réu da sala de audiência, observando-se o disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, Hudson e Israel, após o que o réu foi interrogado. AS PARTES NÃO SE OPUSERAM QUE A AUDIÊNCIA OCORRESSE PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA, bem como não se opuseram que a audiência ocorresse de moto remoto. Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Pela Defesa foi dito que: : MMª Juíza, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo outras diligências a serem empreendidas nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, dou por encerrada a instrução criminal, iniciando-se os debates.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, PAULO DE FREITAS GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 20

de outubro de 2022, no horário e local descritos na inicial, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, um liquidificador, no valor de R\$ 600,00, um HD profissional, no valor de R\$ 1.200,00, quatro sanduicheiras e duas garrafas plásticas, pertencentes ao estabelecimento comercial Habib's. Encerrada a instrução probatória, verifica-se que, a ação presente penal deve ser julgada integralmente procedente. Senão vejamos: A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é incontestada. O representante da empresa vítima Habibs, Cristiano Simas dos Santos, ouvido em Juízo, declarou que, é gerente do estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram. Afirmou que, na data dos fatos, durante a madrugada, recebeu ligação da empresa de monitoramento informando que um indivíduo havia adentrado no comércio. A polícia já se encontrava no local e um indivíduo já havia sido detido. Um vidro do estabelecimento foi quebrado com uma barra de ferro. Foram subtraídos, um liquidificador, uma CPU de computador, alguns brindes e refrigerantes. Os bens foram recuperados. Conhecia o acusado de vista, pois ele costumava pedir esfirra na loja. Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, ouvidos em Juízo, ratificaram seus depoimentos prestados em solo policial. Relataram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados via rádio para atender uma ocorrência de furto em andamento no restaurante Habibs. Deslocaram-se até o local. Próximo ao estabelecimento comercial, em um ponto de ônibus avistaram o acusado em poder de algumas sacolas. As características coincidiam com as informadas. Realizaram a abordagem. Dentro das sacolas que ele trazia consigo, foram localizados um modem, um liquidificador, algumas latas de refrigerantes e outros objetos. Questionado acerca dos objetos, o acusado admitiu que havia acabado de furtá-los. Ele afirmou que havia quebrado um dos vidros do restaurante com uma barra de ferro e ingressado no local. Acrescentaram que não conheciam o réu antes do ocorrido. O acusado, ao ser interrogado na fase inquisitorial, confessou integralmente a prática delitiva. Disse que, estourou o vidro do restaurante com uma barra de ferro, ingressou no local e subtraiu os bens descritos na denúncia. Em Juízo, novamente confessou a prática do furto. A prova oral colhida torna certa e irrefutável a responsabilidade do acusado pelo crime de furto descrito na denúncia. O acusado foi detido nas proximidades do local dos fatos, minutos após a ação criminosa, em poder dos bens subtraídos. A par disso, confessou a prática do furto, tanto em solo policial, como em Juízo. É o que basta para a condenação. O crime de furto se consumou. Ainda que por breves instantes, houve inversão da posse. A qualificadora prevista no inciso I (rompimento de obstáculo) do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal restou devidamente comprovada pela prova oral colhida, bem como através do laudo pericial juntado às fls. 128/134. Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que, o acusado é multirreincidente específico, ostentando quatro condenações definitivas anteriores pela prática de crimes de furto, denotando personalidade desvirtuada, voltada para o mundo da criminalidade e refratária aos efeitos ressocializadores da pena, justificando-se a fixação da pena acima do mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria deve incidir a agravante da reincidência. Diante da multirreincidência específica do réu, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Nestas condições, requer o órgão do Ministério Público, a procedência da ação, condenando-se o réu, nos exatos termos da denúncia.

Dada a palavra ao (à) Dr. (A) Defensor (A), por ele (ela) foi dito: MMA. Juíza: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 03h52min, no interior do Restaurante Habibs, situado na Av. Interlagos, 3504, Campo Grande, nesta cidade e comarca de São Paulo, PAULO DE FREITAS GOMES, qualificado à fl. 11, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um liquidificador, no valor de R\$600, 00, um HD profissional, no valor de R\$1.200, 00, quatro sanduicheiras e duas garrafas plásticas de patrulha canina, pertencentes ao estabelecimento comercial Habib's. O Ministério Público requereu a condenação.

II - Insignificância

No caso em tela os fatos descritos são materialmente atípicos, tendo em vista a insignificância da lesão causada pelo réu, por conta do ínfimo valor do bem supostamente subtraído.

A res furtiva foi devidamente devolvida para a vítima, não havendo dano ao patrimônio.

Ainda, conforme reza o princípio do favor rei, sempre deve ser utilizada a interpretação mais benéfica ao acusado¹. Por conseguinte, diante da ausência de valor apontado, ele deve ser valorado como irrisório. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME DE BAGATELA. FALTA DE AVALIAÇÃO DOS BENS FURTADOS. PRESUNÇÃO DO PEQUENO VALOR. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Direito Penal não deve importar-se com bagatelas, que não causam tensão à sociedade. O princípio da insignificância vem sendo largamente aplicado, em especial por ser o Direito Penal fragmentário. (Precedentes) 2. Se os bens furtados não foram avaliados, deve ser presumido serem eles de pequeno valor.

4. Se o valor do bem furtado é ínfimo e da conduta do réu não resultou prejuízo significativo para a vítima, deve ser reconhecido o crime de bagatela.

5. Ordem concedida para, reconhecido o crime de bagatela, absolver o paciente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.” (STJ. HC 140.080/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 08/03/2010)

Portanto, ainda que tenha ocorrido lesão ao patrimônio, bem jurídico tutelado pelo art. 155 do CP, ela foi irrisória, insignificante. Dessa forma, a ação narrada não possui tipicidade material, conforme indica o princípio da insignificância, derivado da fragmentariedade do Direito Penal. Afinal, o Judiciário não deve cuidar de ninharias, “de minimis, non curat praetor”: “Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentaria, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas. (...) a gradação qualitativa e quantitativa do injusto, referida inicialmente (supra, n. 123), permite que o fato penalmente insignificante seja excluído da tipicidade penal”².

A esse respeito, dentre outros: STF, HC 84.412, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 91.920/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; HC 97.129/RS, Rel. Min. EROS GRAU; HC 97.189/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE; HC 96496/MT, Rel. Min. EROS GRAU;

STF, HC 105.974, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC 93393, Rel. Min. CEZAR PELUSO; HC 93.453, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; STJ, REsp 778.795/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ; HC 145357/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; RHC 23.376/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES; HC 198.996/SC, Rel. Min. OG FERNANDES; HC 34.626/MG, Rel. Min. FELIZ FISCHER; HC 139.015/SP, Rel. Min. OG FERNANDES; STJ, HC 122.435/MG, Rel. Min. CELSO LIMONGI.

Esses exemplos indicam requisitos jurisprudenciais exigidos para o reconhecimento da atipicidade postulada: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”.

Diante do valor, o primeiro e o último vetor foram atendidos.

Prosseguindo, não houve periculosidade social da ação e a reprovabilidade do comportamento foi de pequeníssima monta.

Para as últimas duas hipóteses, o parâmetro de avaliação é a conduta do apelante exclusivamente nos fatos pelos quais foi acusado, como determina o princípio da culpabilidade, pautado pelos ditames do Direito Penal do Fato: “Um direito que reconheça, mas que também respeite a autonomia moral da pessoa, jamais pode penalizar o ser de uma pessoa, mas somente o seu agir, já que o próprio direito é uma ordem reguladora de conduta humana. Não se pode penalizar um homem por ser como escolheu ser, sem que isso violente a sua esfera de autodeterminação”³. Logo, é indiferente analisar o histórico criminal.

Ainda, vale ressaltar que o STF consolidou que o histórico, por si, não interfere na avaliação da insignificância:

“Ementa: PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO.

QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos. 4. Ordem denegada. " (STF. HC 123734, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2016 PUBLIC 02-02-2016)

Com isso, tomam-se como paradigma de avaliação seus atos no caso: a ofensividade foi mínima, já que a ação apontada na denúncia não provocou vulnerabilidade relevante da vítima; a lesão foi inexpressiva, diante do valor do bem e de sua recuperação; o comportamento, apesar de reprovável, não gera intenso gravame ou repulsa, quando considerado diante do gigantismo punitivo estatal, sendo reduzido. Logo, os critérios para a aplicação do princípio estão preenchidos.

No caso em tela, o bem jurídico atacado não é considerado de excepcional importância, o valor econômico teoricamente subtraído é baixíssimo e a lesão causada à vítima é quase nula, razão pela qual não há sentido em criminalizar a aludida conduta.

Diante do exposto, deve ser absolvido, nos termos do art. 386, III do CPP.

III – Tentativa

Subsidiariamente requer-se o reconhecimento da tentativa em seu grau máximo, pois a consumação do delito ficou demasiadamente distante de sua conclusão. Explica-se: Realmente, o delito imputado aos apelantes não restou consumado, haja vista que a ação foi percebida e imediatamente comunicada à polícia. Com isso, os apelados foi abordados imediatamente após o crime.

Oportuno colacionarmos o entendimento proferido pelo STF no julgamento do recurso REsp 1.524.450, sob a relatoria do ministro Nefi Cordeiro:

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Assim, em momento algum conseguiu a livre disposição da coisa, configurando-se a tentativa, pois não obteve a posse livre de qualquer objeto da vítima.

Destarte, nada há nos autos que concretize a prática de todos os elementos da definição legal do furto, mormente porque a prova produzida nos autos é tendenciosa em reconhecer estar o apelante ainda no afã de assumir a posse da res. É, no dizer de José Frederico Marques, "a execução iniciada de um crime, que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente".

Portanto, considerando o iter criminis percorrido, imperioso o reconhecimento da tentativa em grau máximo, dois terços.

IV – Regime inicial de penas

O art. 33, §, 2º, b, do Código Penal, estabelece o regime aberto para o réu primário condenado a pena que não supera 04 anos, e semiaberto se não ultrapassa 08. Somente com base nos critérios previstos no art. 59, "caput", é possível impor outro regime, como reza o §3º do art. 33.

Destaca-se que a determinação legal impondo o regime inicial fechado é inconstitucional.

O princípio da individualização da pena, amparado pelo artigo 5º XLVI da CF, impede que a mera natureza do delito baste para justificar a imposição de regime mais rigoroso, vez que desconsidera as circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, intenso debate doutrinário e jurisprudencial se sucedeu, até que o órgão pleno do STF, ao julgar em 27/06/12 o HC 111.840 declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90 com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, em 27/06/2012.

Ou seja, é cabível o regime inicial distinto do fechado para o delito em debate. Além disso, a gravidade insita ao delito é incapaz de embasar a determinação do regime mais gravoso, ao contrário do procedido pelo juízo "a quo", à luz do art. 93, IX, da CF, das súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

A inidoneidade da fundamentação acarreta a alteração do regime inicial:

"(.....)

IV - Segundo jurisprudência pacífica do excelso Supremo Tribunal Federal, "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" (Súmula n. 718/STF), e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n. 719/STF).

V - "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Súmula n. 440/STJ).

VI - In casu, verifica-se que o regime inicial fechado foi determinado tão somente com base na gravidade abstrata do delito, não tendo sido apresentado fundamento concreto para imposição de regime mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena aplicado.

VII - Sendo os pacientes primários, fixada as penas-base no mínimo legal e consideradas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial semiaberto mostra-se mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, mantidos os demais termos da condenação."

(STJ. HC 506.967/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Ademais, a confissão é apta para justificar o estabelecimento do regime menos gravoso, pois indica que as circunstâncias judiciais são favoráveis. Vejamos, para tanto, como se dá o regramento, no caso, para a segunda fase da dosimetria.

O art. 67, do CP, dispõe o seguinte:

"Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência."

Logo, a pena, no segundo momento da dosimetria, deve seguir o parâmetro indicado pelas "circunstâncias preponderantes", as quais englobam a confissão, que faz parte da personalidade do agente. Afinal, diz respeito ao seu comportamento, forma de pensar e agir.

Com isso, concorrendo circunstâncias de igual valor, deve ser operada a compensação entre ambas. Nesse trilha, merece nota a seguinte decisão, destacando-se, inclusive, que a questão foi pacificada pelo STJ ao julgar o ERESP n.º

1.154.752/RS, como exemplifica a decisão abaixo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial, examinar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria.

2. As teses suscitadas no agravo regimental não foram apresentadas no recurso especial, de forma que não é possível a sua apreciação neste momento processual, em razão da indevida inovação recursal.

3. A matéria tratada cinge-se exclusivamente à interpretação de dispositivo infraconstitucional, qual seja, o art. 67 do Código Penal.

4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a atenuante da confissão espontânea está ligada à personalidade do agente e, portanto, é igualmente preponderante em face da reincidência, razão pela qual é possível a compensação entre elas. 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019) Logo, se a confissão é capaz de impedir o aumento obrigatório de uma agravante, cujo rol é taxativo, com maior razão deve embasar o estabelecimento do regime inicial menos gravoso.

Isso porque o artigo 67 do CP estabelece premissa que acarreta ordem decrescente de peso para a aplicação da pena. As atenuantes e agravantes que caracterizam circunstâncias preponderantes têm maior valor do que as demais e, por consequência, maior importância do que as circunstâncias judiciais. Ademais, tanto é assim que aquelas estão previstas em rol expresso e fechado, enquanto essas tratam de elementos abertos.

Dessa maneira, uma atenuante gera redução maior do que o aumento proporcionável por uma circunstância judicial.

Com isso, a personalidade favorável, derivada da confissão, tem valor maior ou, no pior dos cenários, igual ao das circunstâncias judiciais nesse caso, paradigma empregado para estabelecer o regime.

Diante do exposto, deve ser fixado o regime inicial aberto, se a pena não superar 04 anos, ou semiaberto, do contrário.

V - Aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP

A Lei 12.736/12 trouxe no artigo 387, §2º, do CPP a seguinte disposição:

"§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)"

Para a avaliação da correta forma de aplicação do direito narrado, é necessário recorrer à exposição de motivos da alteração em tela:

"Na atualidade, o sistema de justiça criminal é composto de aproximadamente 40% de presos provisórios. Essa realidade ocasiona problemas ao sistema de justiça, em especial no que tange ao cumprimento da pena imposta por aqueles que durante o processo permaneceram presos.

Comumente ocorre que após a sentença condenatória ter sido proferida, tenha o réu que aguardar a decisão do juiz da execução penal, permanecendo nesta espera alguns meses em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus, em razão de não existir previsão expressa no Código de Processo Penal conferindo ao juiz do processo de conhecimento a possibilidade de, no momento da sentença, realizar o desconto da pena já cumprida.

Tal situação, ademais de gerar sofrimento desnecessário e injusto à pessoa presa, visto que impõe cumprimento de pena além do judicialmente estabelecido, termina por aumentar o gasto público nas unidades prisionais com o encarceramento desnecessário. Ademais, atualmente, essa realidade acaba por gerar uma grande quantidade de recursos aos tribunais superiores com a finalidade de se detrair da pena aplicada ao réu o período em que esteve preso provisoriamente.

Atualmente, o Código Penal em seu art. 42, expressamente prevê que será computada na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, administrativa e o de internação no Brasil e no estrangeiro sendo necessário que tal previsão, também conste no Código de Processo Penal.

O que se almeja com o presente projeto, portanto, é que o abatimento da pena cumprida provisoriamente possa ser aplicada, também, pelo juiz do processo de conhecimento que exarar a sentença condenatória conferindo maior celeridade e racionalidade ao sistema de justiça criminal, evitando a permanência da pessoa presa em regime que já não mais corresponde à sua situação jurídica concreta."

A leitura do texto ilustrado deixa claro: a alteração legislativa supracitada surgiu justamente para suprir o trâmite burocrático envolvendo direitos ligados à execução da pena.

Se a fundamentação acima não basta, vale destacar a via crucis do réu condenado e preso, para conseguir a avaliação do direito à progressão: após a sentença condenatória, deve ser expedida a guia de recolhimento provisória (documento sem o

qual inexistia a execução da pena); regularmente o documento não é expedido de pronto, havendo Varas na Capital de São Paulo nas quais ele demora meses para ser confeccionado; após sua emissão, ele deve ser remetido ao juízo das execuções competente para tanto, o que igualmente não é imediato (havendo a possibilidade de devolução sem autuação, caso haja remessa para juízo incompetente, algo que muitas vezes ocorre em São Paulo, pois existem vários órgãos do Judiciário com atribuição para execução penal); depois desse juízo recebê-lo, comumente antes de qualquer apreciação ele é remetido ao setor de cálculo da pena; por fim, seguem-se as manifestações das partes e, finalmente, a decisão judicial, caso não exista decisão de ofício.

Esse caminho mostra que muito tempo se passa até que haja avaliação da progressão. Portanto, por vezes, o direito à progressão de regime é avaliado tardiamente, muito depois do preenchimento do requisito objetivo, ou até mesmo não chega a ser avaliado. Em outros termos, pode ocorrer o cumprimento sem progressão de pena, porque inexistiu avaliação judicial para tanto, diante da burocracia estatal, aliada ao excesso de serviço.

E a situação é agravada quando o indivíduo é preso em flagrante e é mantido encarcerado. Afinal, a todo o tempo já disposto, se soma o período no qual estava custodiado cautelarmente antes da sentença.

Esse é o contexto que gerou a alteração legislativa.

Isso indica que a forma correta de sua aplicação é a que segue.

O regime de cumprimento de pena, hoje, possui duas fases.

No primeiro momento, seguem-se as regras do art. 33, §2º e 3º do CP, levando à primeira fixação.

Depois, é considerado o tempo de prisão provisória, à luz do art. 387, §2º do CPP.

Se a custódia cautelar atingiu, conforme a imputação feita, o requisito objetivo para a progressão de regime, é alterada a fixação inicial para o regime subsequente.

Nesse caminho segue a seguinte decisão:

"(....)

6. No caso concreto, considerando que a escolha do regime prisional pautou-se na gravidade abstrata do delito, bem como que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal foram favoráveis ao paciente, em tese, é possível o início do cumprimento da pena no regime aberto, pois a prisão data de 17.11.2012 e, à época da prolação da sentença condenatória (04.09.2013), o paciente já havia cumprido mais de 1/6 da pena.

7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para estabelecer o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena do paciente em virtude da detração."

(STJ. HC 307.521/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 03/12/2014)

Com isso, tendo em vista que o réu ficou preso durante a instrução do feito, é medida de rigor a alteração para o regime subsequente.

VI - Pedidos

Ante ao exposto, requer a ABSOLVIÇÃO dos acusados com previsão no artigo 386, III, do CPP. Por fim, na hipótese de condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal; aplicação máxima do redutor da tentativa; e, por fim, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, ainda, a progressão prevista no art. 387, §2º, do CPP.

A seguir, pela MMª Juíza de Direito, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Paulo de Freitas Gomes, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque supostamente no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 03hs52min., no interior do Restaurante Habibs, situado na Av. Interlagos, nº 3504, Campo Grande, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um liquidificador, no valor de R\$ 600, 00, um HD profissional, no valor de R\$ 1.200,00, quatro sanduicheiras e duas garrafas plásticas de patrulha canina, pertencentes ao estabelecimento comercial Habib's. A denúncia foi recebida (fls. 93/96), o acusado foi pessoalmente

citado (fls. 121/122), apresentou resposta escrita (fls. 135) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 137), momento em que ouvido o representante da vítima, duas testemunhas e o réu interrogado. Ao final, realizaram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. A ação penal é parcialmente procedente, eis que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime furto descrito na denúncia, todavia, na forma tentada. A materialidade delitiva veio estampada através do boletim de ocorrência (fls. 19/22), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 10), bem como pelo laudo pericial no imóvel (fls. 128/194, que atestou que: "Na folha de vidro que dá acesso para o ambiente reservado, forma constatados sinais de rompimento de obstáculo localizados em sua estrutura devido a existência de fraturas, produzidos força muscular aplicado externamente"). A autoria também é certa. Coram judicis o réu confessou a acusação. Disse que é morador de rua e realmente subtraiu os bens porque estava passando por necessidades. Declarou-se arrependido. Tal confissão restou corroborada pelos demais elementos coligidos nos autos. Com efeito, o representante da empresa vítima Cristiano informou que os vigias do restaurante ligaram por volta das 4 horas da manhã dizendo que alguém tinha entrado no local. Estava se arrumando para sair quando policiais lhe informaram que haviam quebrado o vidro e o indivíduo detido. Foi subtraído um HD, refrigerantes, um liquidificador. Tudo foi recuperado. O réu costumava ir ao restaurante para pedir esfihas. É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores, bem como para narrar as circunstâncias do delito, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, visto que não há razão para que uma pessoa aponte outra como autora de um delito senão for a legítima vontade de vê-la responder por seus atos. Ademais, o policial militar Hudson Axel Magalhães relatou que estava em patrulhamento quando foi informado a respeito de furto em andamento. Chegando ao local avistou o réu saindo do Habib's, próximo do ponto, com uma sacola na mão. Realizada a abordagem no interior da sacola foram localizados os objetos subtraídos. Foi ver o restaurante e constatou que o vidro do restaurante estava quebrado. Não conhecia o réu anteriormente. No mesmo sentido o depoimento do policial militar Israel de Proença Júnior. O fato de os depoentes serem os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer conheciam o réu antes dos fatos, portanto não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente. A função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Ademais, é sabido que a apreensão em poder do réu do objeto furtado, traz a presunção de ser ele o autor do delito. Neste diapasão: "Prova - apreensão da res furtiva - presunção de que o possuidor é o autor do delito - necessidade de o acusado justificar e comprovar, em inversão probatória, a legitimidade da posse" (in RT 822/621). "Prova - res furtiva e encontrada em poder do agente - presunção de autoria - hipótese em que deve ser invertido o ônus da prova, devendo ao acusado demonstrar que não foi responsável pela subtração" (in RT 830/566). A prisão em flagrante de quem está na posse do bem alheio implica no ônus para o suspeito em demonstrar a inocência, pois o quadro lhe é desfavorável, por completo, conforme referto entendimento jurisprudencial: "A prisão em flagrante é a mais cabal, a mais convincente das provas do crime e de sua autoria que a Justiça pode obter, desde que não encontre oposição formada em Juízo que a inutilize ou modifique. Assim, absurdo é que o julgador, ao formar livremente sua convicção, despreze o expressivo elemento" (in JUTACRIM 43/251). Destarte, resta plenamente comprovada de forma segura e harmônica que o réu foi o autor do crime em questão. Além da autoria incontestada também não existem dúvidas quanto à incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, vez que comprovada mediante o laudo de fls. 128/194. Observo, outrossim, que não há empregar aqui o postulado da

insignificância, cujo exame não se dá por mera tabela de valores, mas, sim, em conexão com os princípios da fragmentariedade e da intervenção estatal mínima, para arredar, ou não, a própria tipicidade penal, sob seu prisma material. Mister verificar para tanto, a concomitante presença da mínima ofensividade da conduta do agente, da inexistência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada. E sob tais ângulos de enfoque, tenho como inaceitável a complacência do Estado no caso vertente, porquanto o réu, com ampla folha de antecedentes pelo cometimento de diversos furtos, quebrou o vidro de estabelecimento comercial e subtraiu bens avaliados em mais de R\$ 1.800,00, conduta esta que não pode ser considerada inofensiva, sob pena de nos tornarmos uma anarquia. Vai daí que, sempre respeitada a posição diversa, obstar a atuação do Direito Penal diante deste quadro, afrontaria a proporcionalidade, negando proteção a vítima, em vil aplauso à pequena, porém, ofensiva, sim, criminalidade rotineira que infesta nossa sociedade, sob pena de nos tornarmos uma sociedade sem lei. A jurisprudência mais autorizada do Colendo Superior Tribunal de Justiça oferece o conforto da boa companhia: "Para efeito da aplicação do princípio da insignificância é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Aquele, implica na atipia conglobante (dada a mínima gravidade). A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância" (REsp nº 861.288/RS - 5ª Turma - Rel. Ministro FELIX FISCHER - in DJU de 18.12.2006). De outra banda, verifica-se que o delito não ultrapassou a esfera da tentativa, pois o agente foi surpreendido pelos policiais no momento em que estava saindo do estabelecimento comercial em poder dos bens subtraídos, não conseguindo, portanto, obter a posse da res. Assim é que decido e passo a dosar a pena. Na primeira fase de aplicação da reprimenda, observo que o réu possui maus antecedentes, ostentando contra si condenações anteriores pela prática de delitos patrimoniais (fls. 29/33 - 1ª Vara Criminal - processo nº 0091589-35.2014; 28ª Vara Criminal - processo nº 1512534-33.2019), razão pela qual aumento em um sexto (1/6) a pena-base, fixando-a em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. Na segunda-fase de fixação da reprimenda, observo que o réu é reincidente na prática de furto (fls. 30/31 - 8ª Vara Criminal - processo nº 1523255-10.2020), todavia, confessou a prática delitiva, razão pela qual compenso tais circunstâncias e mantenho a pena tal como originalmente fixada. Em decorrência da tentativa, diminuo a pena em um terço (1/3), considerando, para tanto, o grande "iter criminis" percorrido pelo agente, que já havia quebrado o vidro, separado os objetos subtraídos, colocado no interior da sacola e estava saindo do estabelecimento subtraídos quando foi surpreendido pelos policiais militares, resultando a reprimenda em um (01) ano, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de sete (07) dias-multa. Considerando os antecedentes e reincidência criminal específica do réu, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal (art. 33, do C.P.), ressaltando que inviável o reconhecimento da detração, eis que sequer atingido lapso temporal para eventual progressão. Ante ao exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a acusação e condeno Paulo de Freitas Gomes, qualificado nos autos, à pena de um (01) ano, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de sete (07) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursão no artigo 155, § 4.º, inciso I, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal. Considerando que o réu reincidente e possui maus antecedentes, ostentando contra si condenações anteriores pela prática de crimes patrimoniais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender condicionalmente a pena. O réu não poderá apelar em liberdade, eis que ainda presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva, mormente diante da presente sentença condenatória. Recomende-se no estabelecimento penal em que se encontra. Isento de custas. Publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados."

Dada a palavra ao (à) Dr. (a). Promotor (a) de Justiça, pelo (a) mesmo (o) foi dito que: MMª Juíza, Ciente da sentença, este (esta) Promotor (a) de Justiça não apela.

Dada a palavra ao (à) Dr (a). Defensor (a), foi dito: Ciente da sentença. Desejo apelar da decisão.

O réu tomou ciência da sentença e manifestou o desejo de recorrer da decisão.

Em seguida, pela MM. Juíza foi dito que: Recebo o recurso de apelação interposto pela D. Defesa. Processe-se-o. Diante da manifestação do Ministério Público em não recorrer certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se guia de recolhimento provisória. Oportunamente, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a observância das formalidades legais.

Servirá a presente como ofício de recomendação do sentenciado PAULO DE FREITAS GOMES, Brasileiro, Solteiro, RG 19736676, CPF 09133158851, pai ANTONIO MOREIRA GOMES, mãe DARCI DE FREITAS GOMES, Nascido/Nascida 09/11/1969, de cor Branco. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Pinheiros IV - Av Nações Unidas, 1405, Vila Leopoldina - CEP 53100-00, São Paulo - SP, 11 38313578. Endereço: EM SITUAÇÃO DE RUA, 1, CAMPO GRANDE, EM SITUAÇÃO DE RUA, São Paulo - SP, perante o estabelecimento prisional em que se encontrarem recolhidos.

Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pela magistrada. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Eu, Luciana Emiko Fukassawa, Assistente Judiciário, digitei e assino digitalmente.